

1509197-64.2021.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509197-64.2021.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2309124/2021 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 15840756 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4106/21/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 4108/21/929 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2309124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

CARLOS RODRIGUES VIEIRA GOMES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V, e § 2º-A, inciso I, e do artigo 158, § 3º, primeira parte, c.c. artigo 70, todos do Código Penal, porque no dia 16

de outubro de 2021, na rua José Rodrigues Neto, 287, Bairro Cruzeiro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma carteira contendo documentos pessoais, dois cartões bancários, um aparelho celular marca Xiaomi e R\$ 300,00, pertencentes à vítima Rafael da Anunciação Costa, restringido sua liberdade.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, CARLOS RODRIGUES VIEIRA GOMES, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, constrangeu a vítima Rafael, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além de restringir sua liberdade, com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que se fizesse alguma coisa (transferência bancária por meio de pix da quantia de R\$ 327,00).

Recebida a denúncia aos 17 de dezembro de 2021 (fl. 44), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 63 e 72/73).

Ratificado o recebimento da inicial (fl.98), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 133).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação postulou a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 137/141).

A defesa requereu a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 165/168).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A autoria dos delitos imputados está plenamente comprovada, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que durante seu interrogatório negou a prática das infrações.

Quando questionado sobre o recebimento de um pix realizado pela vítima em sua conta bancária, Carlos defendeu-se dizendo que permitiu que uma pessoa chamada Felipe utilizasse seu documento por alguns dias. Em contraprestação, receberia o valor de R\$ 150,00. Declarou que desconhecia que Felipe iria abrir uma conta bancária em seu nome.

Eis suas palavras:

I: (...) eu realmente aluguei meu documento pra um rapaz chamado Felipe. Eu conheci ele através de um jogo de futebol, senhor. Na onde que ele morava no mesmo bairro que eu, e como eu tava recebendo só por mês, acabei aceitando, senhor, essa proposta dele. Onde que ele foi, pegou meu RG, deixei cerca de duas semanas com ele, ele me deu uma certa quantia, R\$ 150,00 e como eu tava namorando na época eu aceitei.

J.: E como é que o senhor justifica que o dinheiro foi transferido através da conta da vítima pra sua conta, naquele dia do roubo?

D.: Foi transferido pra minha conta, mas, porém, eu não sabia senhor. Porque meu documento foi feito uma conta falsa, no caso eu fui laranja nessa situação senhor.

J.: O senhor não utiliza essa conta, o senhor não movimenta essa conta?

D.: Não senhor.

J.: O senhor nem sabia que existia essa conta?

D.: Não. Porque como eu trabalhava com a minha mãe, o dinheiro que eu recebia lá, eles pagavam na conta da minha mãe, recebia no pix da minha mãe.

Sua escusa não convenceu e restou isolada.

Pontue-se, inicialmente, que durante a etapa policial ele se calou.

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo”.

Somente em Juízo ele se justificou quanto ao recebimento em sua conta bancária de

um pix realizado pela vítima. Contudo, o acusado não comprovou o teor de suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ora, sequer ele identificou a suposta pessoa que teria utilizado seus documentos pessoais, limitando-se a dizer seu prenome. Na mesma esteira, não comprovou que não realizava qualquer movimentação financeira em sua conta corrente.

Ele também não apresentou justificativa por quais motivos poderiam a vítima e testemunhas querer incriminá-lo injustificadamente.

Desta forma, desacreditadas suas palavras, em especial diante do acervo que se reproduzirá adiante.

Em brilhante decisão, da lavra do Des. José Raul Gavião de Almeida, que tomamos da liberdade de reproduzir, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a versão do acusado, quando esposada, deve ser comprovada para merecer confiabilidade.

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta.

Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se.

Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade.

Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito à valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa.

Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da autodefesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional.

Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor.

É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade”.

Se não bastasse a força de convicção íntima em tais elementos, o depoimento harmônico e coerente das testemunhas ouvidas durante a instrução processual corrobora com a certeza da autoria e as materialidades. Senão vejamos.

A vítima Rafael narrou que é motorista e que utiliza o aplicativo “99” para ser contatado pelos clientes. Declarou que naquela ocasião foi acionado por uma mulher, por meio de referido aplicativo, para realizar uma corrida. Contou que quando chegou ao endereço solicitado, foi abordado por dois indivíduos, que adentraram em seu veículo e determinaram que ele transitasse com o carro.

Mencionou que depois de percorrer algumas ruas, os indivíduos determinaram que ele parasse o veículo numa rua escura. Nesse instante, eles anunciaram o assalto e subtraíram sua carteira e seu aparelho celular, bem como exigiram que ele informasse a senha do banco para que pudessem transferir dinheiro de sua conta bancária. Salientou que apenas um dos indivíduos estava com o rosto coberto com capuz e que ambos empunhavam arma de fogo. Explicou que após entregar seus bens e transferir o valor de R\$ 329,00 para a conta por eles informada, conseguiu se desvencilhar dos agentes, fugindo em seguida.

Narrou, ainda, que posteriormente os policiais identificaram o acusado como sendo o destinatário da transferência bancária, via pix, realizada quando dos fatos, oportunidade em que observou que ele “parecia nitidamente” como um dos agentes dos crimes contra si perpetrados, asseverando, inclusive, que ele possuía uma tatuagem no pescoço, no mesmo local daquela que possuía o assaltante.

Por sua vez, o investigador de polícia Jefferson narrou detalhadamente como apurou a autoria em desfavor do acusado. Relatou que a vítima apresentou na delegacia de polícia o comprovante do pix realizado no momento da ação, uma vez que os agentes naquela ocasião, após subtraírem o celular da vítima, exigiram que ela lhes fornecesse a senha para realização da transferência.

Acrescentou que de posse de referido documento, identificou o acusado como sendo o destinatário da conta bancária e exibiu à vítima uma fotografia dele, oportunidade em que ela o reconheceu como sendo um dos agentes, especialmente porque ele possuía uma tatuagem no pescoço.

Suas palavras são confirmadas pelo policial civil Eduardo, que de forma séria e coerente narrou que após a identificação do acusado como sendo a pessoa que recebeu o numerário da conta da vítima, transferida via pix, a vítima compareceu na delegacia e o reconheceu fotograficamente como autor do roubo e da extorsão realizada.

Gize-se, que a vítima na Delegacia de Polícia, conforme auto de fl. 28, declarou que "após olhar atentamente afirma que tal pessoa possui o mesmo porte físico, cor de pele e com tatuagem muito semelhante na região do pescoço, mas devido ao fato de ter ficado muito nervoso no momento do crime não pode afirmar que se trate de um dos autores do roubo".

Portanto, com a indicação trazida pela vítima, especialmente pelo fato de que o acusado possui tatuagem no pescoço, assim como um dos assaltantes, a par da identificação da conta bancária pertencente a ele como sendo a que recebeu o numerário efetivado por meio da transação bancária (pix), avalizado pelas palavras das testemunhas, tornou-se indubitável a autoria.

Ademais, a vítima apresenta versão integralmente segura. Especial atenção deve ser dada à palavra da vítima.

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto". "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si".

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DA RÉU. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pela testemunha arrolada pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. 2. A apreensão da "res" em poder do agente, em situação comprometedor, constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as consequências do crime patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. 3. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 4. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 5. Refazimento da dosimetria da pena.

Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa (crime cometido em concurso de agentes), o regime prisional refletindo inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. 6. Parcial provimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00355702020128260554 SP 0035570-20.2012.8.26.0554, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 26/08/2015).

Nem se diga que o reconhecimento ocorrido perante a Autoridade Policial está emanado de nulidade, uma vez que as formalidades previstas na lei podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À POSSE DO BEM ROUBADO PELO RÉU. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Inexiste nulidade no reconhecimento do réu por fotografia na fase inquisitória quando há outros elementos de prova corroborando a condenação. 2. A palavra da vítima, de que reconheceu o réu por meio de foto, aliada ao fato do agente ter sido preso na posse direta da moto roubada, é suficiente para a condenação. 3. As circunstâncias judiciais devem ser analisadas em favor do agente quando não há elemento concreto apto a tornar a conduta mais gravosa do que aquela ínsita ao tipo. 4. Dispensa-se apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo. 5. Preliminar rejeitada, no mérito, dado parcial provimento ao recurso da defesa (2º) e provimento ao apelo ministerial (1º). (TJ-MG - APR: 10024122102023001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/01/2014).

DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. VALIDADE PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. NÃO APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO CONFIGURADO. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando se encontram acostadas aos autos peças comprobatórias da materialidade e da autoria do crime. 2. Aperícia da arma é dispensável à caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, sendo suficiente a evidência por outras provas coligidas aos autos, em especial, a palavra da vítima. 3. As formalidades legais previstas no artigo 226 do CPP podem ser dispensadas quando é possível a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo. O reconhecimento fotográfico tem real valor probante quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório. 4. Se devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal. 5. Considerando que a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada face à manutenção dos motivos que autorizaram a custódia cautelar da apelante, não merece ser acolhido o pedido para recorrer da sentença em liberdade. 6. Recurso da ré não provido. Recurso do réu parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20121110030460 DF 0002817-18.2012.8.07.0011, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 29/01/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 131).

Assente-se, ainda, que a apreensão do produto do roubo em poder do acusado (comprovante de transferência bancária, via pix - fl. 18) assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório.

Neste sentido:

Roubo - Apreensão da "res" em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da "res" em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Momento consumativo - Entendimento. O entendimento jurisprudencial

que vem predominando, inclusive no Pretório Excelso, tem como consumado o roubo, tão-só, pela subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que, em ato contínuo, de imediato, o próprio ofendido detenha o agente e recupere a "res". Roubo - Desclassificação para furto - impossibilidade. Não há que se falar em desclassificação do delito de roubo para o de furto quando a violência é empregada / contra pessoa e não contra coisa. (TJ-SP - APL: 990100444972 SP, Relator: Wilson Barreira, Data de Julgamento: 01/07/2010, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/07/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - POSSE INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto probatório, prevalece sobre a negativa do agente. - A confissão extrajudicial, sendo verossímil e corroborada pelo arcabouço probatório, deve prevalecer sobre a retratação. - A posse injustificada da res furtiva gera a presunção de autoria, invertendo-se o ônus probatório, incumbindo ao agente demonstrar a licitude da aquisição do bem. (TJ-MG - APR: 10393140019646001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 14/02/0016, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2016).

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, que não se escusou de maneira convincente ante o conteúdo das provas existentes, deve ser considerada certa sua autoria.

O acusado, agindo na companhia de mais um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens da vítima, dentre eles seu aparelho celular. De posse de referido bem, constrangeu a vítima a fornecer a senha de sua conta bancária, permitindo-lhe, destarte, transferir quantia em dinheiro para a sua conta. Logo, após o roubo, praticou a extorsão.

O delito de extorsão, por ser formal, se consuma com a exigência da vantagem indevida.

Sobre o assunto, leciona Rogério Sanches Cunha:

[...] Diverge a doutrina acerca do momento consumativo do delito. Para a maioria, o crime é formal (ou de consumação antecipada), perfazendo-se no momento em que o agente emprega os meios aptos a constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica (o enriquecimento indevido constitui mero exaurimento, a ser considerado na fixação da pena). Precisamente no momento do constrangimento é que o bem jurídico principal (patrimônio) sofre o perigo de lesão. A ofensa ao bem jurídico se dá, no caso da extorsão, pelo perigo. Na eventualidade de que o agente alcance o resultado, ocorre lesão efetiva ao bem jurídico patrimônio. Mas essa lesão é mero exaurimento do crime. (Manual de direito penal: parte especial - arts. 121 ao 361 - . Salvador: Juspodivm, 2018. p.317)

Nesse mesmo sentido é o Enunciado n. 96, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

" O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida "

Na espécie, a exigência do acusado foi no sentido de que a vítima lhe informasse a senha de sua conta bancária, a fim de que ele pudesse efetuar o pix. Saliente-se que durante a realização dessa operação bancária o acusado manteve a restrição da liberdade da vítima e proferiu novas ameaças.

Portanto, vê-se claramente que o constrangimento empregado mediante utilização de uma arma de fogo foi o mesmo durante toda a ação, uma vez que o objetivo do acusado era a obtenção da vantagem indevida, após a subtração de bens.

A materialidade dos delitos está evidente diante do conjunto probatório elencado. Os boletins de ocorrência (fls. 11/14), o relatório do setor de investigação (fls. 17/20, o comprovante da transação bancária (fl. 18), o autor de reconhecimento (fl. 28), aliados às palavras da vítima e testemunhas demonstram a subsunção das condutas do acusado aos tipos denunciados

Quanto à causa de aumento descrita no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do

Código Penal (A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), é evidente que ela incidirá.

A vítima foi firme em detalhar o emprego de arma de fogo. Ademais, é desnecessária a apreensão da arma para a incidência desta causa especial. "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado seu poder vulnerante". "A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação".

E mais:

ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. Recursos defensivos. PRELIMINAR. Pedido de produção de prova (MARCOS) conhecido como questão prejudicial e rejeitado. MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Preservação das causas de aumento, porque amplamente comprovadas pelo acervo. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo. DOSIMETRIA. Afastamento do acréscimo operado nas bases de FRANK e GILVAN. Inteligência da Súmula/STJ, nº 444. Redução das penas de GILVAN e MARCOS. Correção de erro aritmético. Regime fechado obrigatório. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. Impertinência. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 0011022-90.2015.8.26.0176; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Ausência de fragilidade probatória - Condenação mantida. Artigo 226 do Código de Processo Penal - Mera recomendação - Inobservância que não tem o condão de macular o feito - Preliminar rejeitada. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Dupla majoração - Gravidade concreta do delito - Possibilidade - Regime fechado - Pena superior a oito anos. Concurso formal - Reconhecimento - Possibilidade - Em uma única ação foram vulnerados patrimônios diversos - Recurso da Defesa improvido e o do Ministério Público provido para aplicar o artigo 70 do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 1501034-20.2019.8.26.0082; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).

Prosseguindo, muito embora demonstrada a causa de aumento descrita no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal: "se há concurso de duas ou mais pessoas", ela não será utilizada diante da incidência da causa de aumento acima mencionada (§ 2º-A, inciso I, do Artigo 157, do Código Penal, recente alteração trazida pela lei nº 13.654/2018).

A teor do que estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, na hipótese, aplicada causa de aumento com maior rigor, deve ser desprezada eventual outra causa.

Nesta esteira:

ROUBO MAJORADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de rigor a manutenção do édito condenatório. DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, COM VISTAS A EVITAR A EXCESSIVIDADE DO RESULTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO SOMENTE DO AUMENTO PREVISTO NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1503316-27.2019.8.26.0536; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Por fim, a causa prevista no parágrafo 2º, inciso V, do artigo 157, do Código Penal: "se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade", não deve ser aplicada. Para incidência nesta causa há necessidade de que a restrição da liberdade da vítima seja por tempo razoável e em circunstâncias que extrapolem a

grave ameaça componente do próprio roubo, fator que não ficou demonstrado pela prova dos autos.

Verificou-se que o acusado e seus comparsas mantiveram a vítima sob seus controles apenas para realização da subtração. Logo, não se ultrapassou com esta conduta os elementos contidos no próprio roubo.

A seguir, analisaremos a forma de concurso de infrações denunciada (artigo 70, CP - concurso formal), ante a quantidade de infrações cometidas.

Analisando os autos, ao contrário da manifestação ministerial, é possível identificar que o acusado cometeu dois crimes distintos. O delito de roubo se consumou no momento em que subtraiu bens móveis de propriedade da vítima, tais como sua carteira e seu aparelho de telefone celular, ao passo que o crime de extorsão - que é formal - consistiu na conduta de, após subtrair referidos bens, ter exigido a senha utilizada no aplicativo do banco, instalado no celular, para que pudesse realizar transferência de numerário.

Confira-se a narrativa apresentada pelo ofendido em juízo, que se mostra bastante elucidativa a respeito da dinâmica dos fatos:

"(...) Fomos até uma rua escura, não me recordo o nome dela, aí elesderam início, deram a voz de assalto mesmo né. Pediram a minha carteira, o dinheiro que eu tinha feito das corridas, e também, posteriormente, solicitaram que eu fizesse pix de todas as minhas contas. Aí eu entrei em uma das minhas contas, falei que era só aquilo que eu tinha e fiz o pix pra eles. Foi basicamente isso o ocorrido".

Como se sabe, no crime de roubo, o autor exerce a subtração, tomando para si ou para outrem a coisa móvel pertencente ao sujeito passivo, após reduzir ou eliminar sua resistência mediante emprego de grave ameaça ou violência. Já na extorsão, o autor constrange a pessoa, mediante emprego violência ou ameaça, com o fim de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, ou a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Assim, tem-se que, no crime de roubo, a conduta da vítima tem menor importância, uma vez que o agente pode conseguir o que almeja ainda que ela nada faça, ao passo que, na extorsão, a conduta do ofendido é fundamental para a obtenção da vantagem indevida que o sujeito ativo busca, pois, sem ela, ele não alcançará tal vantagem, por maior que seja a violência empregada.

Destarte, evidente que o crime de roubo não constitui meio necessário ou normal fase de preparação ou execução para a extorsão, que seria o crime-fim, razão pela qual não há se falar em relação de continente-conteúdo entre eles, tornando inviável a aplicação do Princípio da Consunção. Também não há que falar em uma única conduta, com dois crimes distintos. No caso, ficou evidente a diversidade de condutas, praticadas em concurso material.

Neste sentido, a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS, PRATICADAS EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES.1. Segundo a

jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça, subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material. 2. No caso, os agravantes, após subtraírem os bens da vítima, restringiram a sua liberdade, retendo-a no interior do seu automóvel juntamente com a sua filha, e a obrigaram a fornecer a senha do cartão bancário, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demonstram a existência de desígnios autônomos e distintos, evidenciando-se o concurso material e não crime único. 3. Ademais, ambas as turmas da Egrégia Terceira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, a despeito de serem da mesma natureza, são infrações de espécies diferentes, razão pela qual não há como admitir a continuidade delitiva.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015). PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONDUTAS DIVERSAS. CONCURSO MATERIAL.

SÚMULA 96/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A conduta do agente, consistente em subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, em exigir a entrega do cartão bancário e senha, embora realizada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão. Precedentes. 2. A afirmação da Corte a quo de que não se chegou a realizar a retirada de dinheiro em caixa eletrônico, com o uso da senha da vítima, é irrelevante para a configuração do crime de extorsão, nos termos da Súmula 96/STJ. (...) (REsp 1255559/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013)
Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECOTE DAS MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Conforme entendimento sufragado pelo STJ, a conduta do agente, consistente em subtrair bens da vítima mediante grave ameaça e, no mesmo contexto fático, exigir a entrega de cartão bancário e senha, caracteriza de forma autônoma, os delitos de roubo e extorsão, não tem lugar a aplicação do princípio da consunção. - A apreensão e o exame pericial da arma configuram-se dispensáveis ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, se extraídos do conjunto probatório elementos de convicção suficientes a demonstrar a utilização do artefato em empreitada delitativa. Precedente STF. - Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena. - Extraíndo-se da prova produzida a existência de condutas com desígnios diversos, não se há falar em concurso formal próprio de crimes. - Não sendo adequadamente sopesadas as circunstâncias judiciais a permearem a ação delitativa, a redução da pena é medida de rigor. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.279117-9/001, Relator (a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2014, publicação da sumula em 07/07/2014)

E ainda:

APELAÇÃO. DENÚNCIA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO DULPAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REFORMA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMOU TER SIDO O RÉU UM DOS AUTORES DOS CRIMES. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE BEM MÓVEL COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. 1. As autorias dos crimes de roubo e de extorsão restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ. 2. Ausência de nulidade no

reconhecimento de pessoa. A colocação de outras pessoas ao lado do réu é uma mera recomendação do Código de Processo Penal. Art. 226, II, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. 3. Roubo. Desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal ou de furto. Impossibilidade. Grave ameaça configurada. 4. Emprego de arma de "fogo" devidamente comprovado pelas palavras da vítima, que disse ter sido abordada pelos roubadores, que se encontravam armados. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF. Reforma. 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 6. Restrição da liberdade da vítima, comprovada pela prova oral judicial, corroboradora da não menos robusta prova oral extrajudicial, haja vista ter ela permanecido por tempo juridicamente relevante (aproximadamente trinta minutos) em poder dos roubadores, no interior do veículo. Precedentes do STJ. 7. Roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. Precedentes do STF. A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.499.050/RJ – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 14.10.2015). Por fim, a cristalizar, definitivamente, o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça aprovou, no dia 14 de setembro de 2016, a Súmula n. 582, cujo texto diz o seguinte: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 8. É medida de rigor a condenação do réu pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal), uma vez que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima. 9. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula n. 96, do STJ. 10. Crime único ou continuado entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. É clássica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes não se qualificam como fato típico único. Ainda, não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. Aplicabilidade do princípio da consunção. Impossibilidade. É que vale ser esclarecido que o princípio da consunção somente deve ser aplicado quando forem praticados crimes que tenham nexos de dependência entre si, de modo que o primeiro delito, também conhecido por crime-meio, ficará absorvido pelo segundo – crime-fim – , solucionando, portanto, o conflito aparente de normas, o que não foi o caso dos autos. Isso porque, em situações como a dos autos, nas quais a vítima é roubada e depois extorquida, restam configurados dois crimes autônomos, o primeiro, de roubo triplamente majorado e o segundo de extorsão qualificada. Impossível, portanto, a tese de ocorrência de delito único ou do crime continuado. Inteligência da Doutrina e precedentes do STF (HC 113.900 – 2ªT. – Rel. Min. Teori Zavaski – DJe 19.11.2014 e HC 121.395/DF – 1ªT. – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 21.10.2014 – DJe 21.11.2014) e do STJ (HC 127.320/SP – 6ªT. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 07.05.2015 – DJe 15.05.2015; HC 185.815/SP – 6ªT. – Rel. Min. Marilza Maynard – Desembargadora Convocada do TJ/SE – j. 04.02.2014 e Resp n. 1.255.559/DF – 6ªT. –

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 11.06.2013). Aplicação das regras do concurso material de crimes. É medida de rigor a manutenção da imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de roubo. Fixo, ainda, o regime fechado para o cumprimento da pena do crime de extorsão qualificada, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa, sem se olvidar da sua reincidência, a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF. Detração penal. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente deve ser operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ. Negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso Ministerial, com ordem de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu.(TJ-SP - APL: 30355786820138260405 SP 3035578-68.2013.8.26.0405, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 25/09/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2018).

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelo condenado não justifica aumento nas penas-base. Seus antecedentes não recomendam exacerbação. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos e consequências dos crimes não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. Contudo, as circunstâncias do crime de roubo justificam maior exasperação. Pontue-se que o acusado agiu na companhia de uma pessoa não identificada (concurso de agentes), fator que justifica maior reprovabilidade.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo as penas do roubo em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data. Para o crime de extorsão qualificada, as penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Na terceira etapa, reconhecida a causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), as penas do roubo serão elevadas em 2/3 ($5 \text{ anos} + 2/3 = 8 \text{ anos e } 04 \text{ meses de reclusão}$ / $12 \text{ dias} + 2/3 = 20 \text{ dias-multa}$).

As penas serão somadas em razão das regras do concurso material de infrações. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, considerando as penas aplicadas e a gravidade dos delitos, com violência e grave ameaça à pessoa.

"O regime fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais intranquilizadoras expressões da criminalidade nos tempos correntes".

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa. Precedentes. 2. Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado

exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 4. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, a audácia do Paciente, que praticou os delitos, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública e à noite, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta delituosa. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (STJ - HC: 459546 SP 2018/0175677-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) desclassificação para o crime de furto; b) fixação da pena base no mínimo; c) reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência; d) fixação de regime diverso do fechado. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e do policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena corretamente aplicada. 3. Regime prisional fechado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - APR: 15072571220188260506 SP 1507257-12.2018.8.26.0506, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2020)

Apelação. Crime de roubo. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma, fixando o regime fechado para início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso da Defesa visando: (i) afastar o emprego da majorante; (ii) o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. 1. A ausência de exame pericial na arma não obsta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, par.2º, I, do Código Penal. 2. Os dados empíricos da causa traduzem um grau de culpabilidade que impõem o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APL: 00023261220148260108 SP 0002326-12.2014.8.26.0108, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 26/01/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2017).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR CARLOS RODRIGUES VIEIRA GOMES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, e artigo 158, § 3º, primeira parte, c.c. artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de

30 (trinta) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

As penas aplicadas e a gravidade do crime impedem qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos